

1502161-18.2021.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Pinati da Silva

Comarca: Cubatão

Foro: Foro de Cubatão

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 09/06/2022

... - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GILBERTO DE OLIVEIRA ALBINO JUNIOR

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Pinati da Silva

Vistos,

I - RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado de São Paulo, por meio de seu representante legal, em exercício nesta Comarca, no uso de suas atribuições legais, com base em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cubatão

Foro de Cubatão

2ª Vara

Av. Joaquim Miguel Couto, 320, Cubatão - SP - cep 11500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1502161-18.2021.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502161-18.2021.8.26.0536

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GILBERTO DE OLIVEIRA ALBINO JUNIOR

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Pinati da Silva

Vistos,

I - RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado de São Paulo, por meio de seu representante legal, em exercício nesta Comarca, no uso de suas atribuições legais, com base em incluso auto de inquérito policial, ofereceu denúncia contra, GILBERTO DE OLIVEIRA ALBINO JUNIOR, tendo-o por incurso no artigo 35 da lei n.º 11.343/06, imputando-lhe os seguintes fatos: desde data e em local incertos, porém até o dia 23 de junho de 2021, nesta cidade e comarca de Cubatão, associou-se com indivíduos não identificados para o fim de praticar, reiteradamente ou não, crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

O réu foi preso em flagrante e a prisão convertida em preventiva [fls. 83/89].

Notificado e citado, nos termos do artigo 55 da Lei n. 11.343/06 [fls. 179], o réu, por intermédio de Defensor dativo, apresentou resposta [fls. 188/192].

A denúncia foi recebida em 03 de setembro de 2021 [fls. 170].

Designada audiência, na qual foram ouvidos duas testemunhas, bem como realizado interrogatório do réu com registro em mídia digital.

Em memoriais finais, o Ministério Público entendeu estar devidamente comprovada a

materialidade e a autoria do delito, bem como a responsabilidade criminal do réu, pugnano pela condenação nos termos da peça acusatória, discorrendo sobre a dosimetria.

Por sua vez, em seus memoriais a Defesa do réu pleiteou sua absolvição por não estar provado que o réu não concorreu para a infração penal [art. 386, inciso IV do CPP] visto que não há provas do seu conluio com os demais agentes. Em caso de condenação, a fixação da no mínimo legal e regime inicial aberto [artigo 33, §2º, alínea 'c'], vez que preenche os requisitos previstos no artigo 44 do CP.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Processo em ordem, com a presença das condições da ação e observância das formalidades legais, sem nulidades a sanar.

A pretensão punitiva é parcialmente procedente.

A materialidade está demonstrada pelo boletim de ocorrência [fls. 56/57], pelo auto de apreensão e exibição [fls. 58], laudo pericial (telefone celular) [fls.216/238], além da prova oral produzida em juízo.

A autoria é certa e deve ser imputada ao réu, porque demonstrada pelo auto de prisão em flagrante [fls.02] bem como comprovada pelos depoimentos dos policiais civis.

A tese defensiva, como se verá, está isolada nos autos

José Aroldo Montenegro, policial civil, informou que no dia dos fatos realizou diligência na residência do réu localizada na Vila Esperança para cumprir mandado de busca e prisão. Foram divididos em duas equipes. Foi na residência dos familiares do réu que não se encontrava no local enquanto a outra equipe foi responsável por deter o réu em um barraco próximo. Foi apreendido um celular e uma televisão. Foi encontrado no aparelho conversas com grupo de traficantes. A irmã do réu acompanhou os policiais até outro local. O réu afirmou que o celular era dele. Não verificou o conteúdo do celular. Não se recorda do vulgo do réu. O mandado era referente a um homicídio. Não tem conhecimento de nenhuma prisão em relação ao réu. No momento da prisão o réu não deu nenhuma explicação. Não participou das diligências, foi chamado apenas para cumprir o mandado.

Fabio Vieira Mendes, investigador de polícia, informou que anteriormente ao fato o réu foi investigado por um crime grave [extorsão mediante sequestro com resultado morte], tendo sido identificado um ano do início das investigações. Mandado de busca e apreensão foi deferido. O réu foi encontrado no barraco dormindo. No local foi encontrado um aparelho celular da marca Motorola. Afirma terem autorização da 4ª vara para extrair e verificar os dados do aparelho celular. Manuseando o aparelho celular, foram encontrados grupos: “família 13”, “união da favela” e “futebol na praia”. Nesses grupos o réu era ativo. Falavam sobre ações policiais, biqueiras, locais determinados da favela de conhecimento da polícia [prainha, floresta, chatuba]. Não conhecia o réu. O telefone celular estava dentro do barraco com o réu. O réu afirmou a posse do aparelho. Ao ser indagado pelo outro crime, o réu ficou em silêncio. O réu era conhecido como vulgo “Queixada” ou “Queixão”, cuja característica física condiz. Não se recorda do nome do réu no grupo, porque usava outro codinome no grupo. A diligência realizada para identificar o réu como olheiro foi a apreensão do celular onde constatarem a troca de mensagens com o intuito de ajudar o crime, estando na condição de olheiro.

Interrogado em juízo, o réu Gilberto de Oliveira Albino Júnior negou os fatos. Informou ter o apelido de “Queixada” e “Júnior”. Seu celular foi apreendido, cuja linha não se recorda, pois o encontrou na rua. O modelo do aparelho era MOTO E 7Plus. Possui uma madrinha chamada Jordania Gomes Queiroz e informou que “tia rango” é uma senhora que vende marmite. “Mano da Aspil”, “Jonatan Aspil” e “Nego Polenta” são seus amigos. Estava dormindo quando abordado por dois policiais que apreenderam seu telefone sobre a cama. Informou a senha para os policiais verificarem o aparelho. O grupo “família 013” contém mais de cem pessoas e é conhecido como grupo da “sintonia”, composto dos moradores do bairro. Utilizava o grupo para informar quando a polícia passava. Já alertou sobre a polícia cerca de cinco vezes. Avisava no grupo para “as pessoas que devem”, não sabe dizer quem eram as pessoas, pois eram muitas no grupo. O grupo “união da favela” tem a mesma finalidade do grupo “família 013”; também “futebol na praia”. Sabia que comunicava

a passagem ou existência da polícia para que alguém no grupo que exercesse a atividade de tráfico de drogas soubesse. Não recebia vantagem a partir dessa comunicação. Afirma estar arrependido de integrar os grupos.

Essa é a prova oral constante dos autos.

Consigne-se que os inquiridos expuseram satisfatoriamente os fatos, sendo certo que os relatos são dignos de credibilidade, não se percebendo qualquer tentativa de falsear a verdade, porque convincentes e provenientes de pessoas cuja idoneidade não foi posta em dúvida, sem indícios de possuíam interesse em prejudicar o acusado, a quem não conheciam, ignorando-se nos autos notícia de desavença ou fato pretérito que indicasse falsa incriminação.

O réu confessou os fatos narrados na denúncia, alegando que transportava munições e tinha em depósito arma de fogo, a qual utilizava para proteção familiar, haja vista que mora e trabalha em sítio, refutando qualquer adulteração.

A confissão foi corroborada pelo depoimento dos policiais militares, que expuseram os fatos de modo coerente e harmônico com todo o contexto probatório.

Ressalte-se, ademais, que não se pode imputar conduta parcial genericamente aos policiais, que, no cumprimento da missão que lhes foi confiada pelo constituinte [CF, art. 144], apresentam transgressores da ordem jurídica ao Estado-Juiz para serem processados, segundo o devido processo legal, que fornece instrumentos para confirmar ou rechaçar a versão dos fatos apresentada pelos agentes estatais de segurança pública. Como assentado no E. Supremo Tribunal Federal, "[o] depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência" [STF - HC n. 73518, rel. Min. Celso de Mello, j. 26.3.1996].

Destarte, o contexto probatório está a evidenciar a prática do crime, de modo que todas as provas produzidas formam um conjunto probatório harmônico e desfavorável ao réu, autorizando, assim, um juízo de certeza para o decreto condenatório.

A imputação fática permite qualificação jurídica distinta daquela indicada na denúncia, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal. Trata-se da *emendatio libelli* que não cerceia a defesa, porquanto o réu se defende de fatos e não da capitulação jurídica.

A prova dos autos assegura a prática criminosa descrita no art. 37 da Lei n. 11.343/06.

Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas exige-se, além do concurso mínimo de duas pessoas, prévio ajuste entre agentes que comunquem o propósito de, reiteradamente ou não, praticarem as condutas previstas nos arts. 33, caput e §1º, e 34, da Lei n. 11343/2006, com certo grau de estabilidade e permanência, elemento subjetivo específico exigido para distinção de mera prática delitiva em concurso de agentes, sendo prescindível a efetiva realização das condutas criminosas referidas, por se tratar de crime formal e de perigo abstrato. De outra parte, leciona Guilherme de Souza Nucci que "(...) o intuito do legislador, ao adotar no tipo penal do artigo 37, da Lei nº 11.343/06, a teoria pluralista do concurso de agentes não foi a de alcançar aqueles que exercem funções habituais no tráfico, como o 'olheiro', pois este é coautor da conduta descrita no artigo 33, mas sim aqueles que normalmente não integram a associação criminosa, em suas diversas funções hierárquicas, mas acabam colaborando com informações privilegiadas e estratégicas para o exercício da traficância(...)." [Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Editora Forense, 8ª edição fl. 367]. Ainda destacando a eventualidade enquanto critério de distinção de conduta: "Apesar de não expresso no dispositivo legal, entendemos que a conduta do informante colaborador necessariamente precisa ser eventual. Seria somente a conduta daquele agente que, sem estabelecer qualquer vínculo associativo com os destinatários das informações, contribui eventualmente com informes, seja mediante remuneração ou por qualquer outra vantagem. Comprovando-se que a contribuição não se mostra eventual, mas permanente e estável, com o estabelecimento de verdadeira *societas sceleris* com os destinatários da informação, a conduta não mais se tipificará no delito em

estudo, mas sim na associação para o tráfico" [Andrey Borges de Mendonça e Paulo Roberto Galvão de Carvalho, Lei de Drogas, Método, 2006, p. 99/101].

Também assim já se decidiu: "(...) A conduta de olheiro tanto pode se enquadrar no delito tipificado no artigo 37 como nos artigos 33 ou 35 da Lei n.

11.343/2006, a depender da comprovação da estabilidade ou não do vínculo. 2. Assim, se restar comprovado nos autos que o indivíduo colabora com o grupo prestando informações de forma esporádica, eventual, sem vínculo efetivo, a conduta se encaixará na norma descrita no artigo 37 da referida lei. Ao contrário, se ficar demonstrado que a função é exercida de forma estável, constituindo-se o modo pelo qual o agente adere aos fins do grupo criminoso, a hipótese será enquadrada no crime do artigo 35, ou mesmo, 33 da Lei Antidrogas, a depender das circunstâncias" [STJ, AgRg no REsp n. 1738851, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 21.8.2018].

É o caso dos autos, à vista da eventualidade das informações pelo réu, conforme mensagens exibidas a fls. 28/47, não se desincumbindo o Ministério Público do ônus de provar a estabilidade e permanência do réu com o grupo criminoso, não bastando, por si, o fato de o réu integrar grupos de mensagens com traficantes, mormente considerando a ausência de nítida atribuição de função ao réu na estrutura criminosa e a expectativa legítima daqueles na sua conduta colaborativa. A informação policial do envolvimento efetivo do réu com o tráfico de drogas não encontra guarida em elemento probatório dos autos.

Assim sendo, o fato é típico e antijurídico, sendo certo que a significância da lesão ao bem jurídico tutelado impõe a incidência da norma penal, não estando o acusado amparado por qualquer causa de exclusão da ilicitude ou que afaste sua culpabilidade.

Passa-se à individualização da pena, nos termos do art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, segundo o sistema trifásico, nos termos do art. 68 do Código Penal, atentando-se às circunstâncias legais, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

A culpabilidade, entendida como grau maior ou menor de reprovabilidade da conduta no caso concreto, é normal ao tipo. O acusado não registra maus antecedentes. A conduta social e personalidade ["deve-se verificar a sua boa ou má índole, sua maior ou menor sensibilidade ético-social, a presença ou não de eventuais desvios de caráter de forma a identificar se o crime constitui um episódio acidental na vida do réu" [Cezar Roberto Bitencourt, Tratado de Direito Penal, Parte Geral, v. 1, 12ª ed., Saraiva, 2008, p. 588], à míngua de elementos de provas objetivas desabonadores, são favoráveis ao réu. O motivo do crime integra sua definição típica, e, portanto, a necessária censura consta na pena mínima abstrata. As circunstâncias e consequências do crime (estas especialmente graves dada a colaboração prejudicial ao exercício do poder de polícia contra o tráfico de drogas) são intrínsecas ao delito não exigindo maior reprimenda. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o impulso delitivo do agente, fato, todavia, que não agrava a pena por se tratar de circunstância neutra [cf. STJ - HC n. 217.819, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura].

Pena-base no mínimo legal.

Em segunda fase, não há circunstâncias agravantes a sopesar, sendo certo que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal mesmo em razão da confissão [STJ, súmula n. 231].

Pena intermediária sem alteração.

Na terceira fase, não há causa de aumento ou de diminuição de pena.

A pena definitiva é de 2 anos de reclusão, com 300 dias-multa.

Em vista da situação econômico-financeira do réu, fixo o valor do dia multa em 1/30 [um trinta avos] do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos [CP, art. 49], que será corrigido monetariamente na ocasião oportuna.

O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade será o semiaberto, na forma do disposto no art. 33, caput, e seu § 2º, alínea c c/c § 3º, do Código Penal.

Ademais, os dados fáticos da conduta delitiva, quando demonstrarem a gravidade concreta do crime, como no caso [conduta prejudicou efetivamente a atuação policial

ao tempo que promoveu o livre exercício do tráfico em detrimento da saúde pública], poderão ser invocados pelo julgador para a imposição de regime mais gravoso do que o permitido pelo quantum da pena (HC n. 279.272/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 5ª T., DJe 25/11/2013; HC n. 265.367/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 5ª T., DJe 19/11/2013; HC n. 213.290/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 4/11/2013; HC n. 148.130/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 3/9/2012).

Considerando, contudo, o tempo de prisão cautelar do réu, na forma da regra do §2º do art. 387 do Código de Processo Penal, o regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade será o aberto, na forma do disposto no art. 33, caput, e seu § 2º, alínea c c/c § 3º, do Código Penal.

Tendo em vista o preenchimento dos requisitos alinhados no art. 44, do CP e seu §2º, substituo a pena privativa de liberdade imposta por 2 [duas] penas restritivas de direito, a saber: prestação de serviço à comunidade [art. 46, CP] em entidade a ser designada pelo juízo das execuções penais [LEP, art. 66, V, a] e prestação pecuniária [art. 45, §2º, CP] no importe de dez dias-multa a ser revertido em favor de entidade designada pelo juízo da execução.

Assim, procedo à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade. O local e a forma de cumprimento da pena serão definidas pelo Juízo da Execução.

Fica o réu advertido de que no caso de descumprimento injustificado das restrições impostas, as penas restritivas de direitos serão convertidas em privativa de liberdade, conforme disposto no § 4º do artigo 44 do Código Penal, com seu recolhimento à prisão.

Considerando a substituição da pena privativa de liberdade, não se há falar em sursis.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e, em consequência, CONDENO GILBERTO DE OLIVEIRA ALBINO JUNIOR, qualificado anteriormente, às penas de 2 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, com detração para o aberto [CPP, art. 387, §2º], com 300 dias-multa, no mínimo legal, por incurso no art. 37, caput, da Lei n. 11.343/06, na forma do art. 383 do Código de Processo Penal.

Não estão presentes os pressupostos fáticos de cabimento da prisão preventiva.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA imediatamente.

Inaplicável à hipótese a fixação do valor mínimo para reparação de danos [CPP, art. 387, IV] por se tratar de crime vago.

Após o trânsito em julgado: (a) expeça-se guia de execução para encaminhamento ao juízo das execuções criminais; (b) oficie-se ao TRE-SP, para os fins do art. 15, III, da CF e (c) oficie-se ao IIRGD para registro de antecedentes criminais.

Fixo os honorários advocatícios ao patrono do réu, nos termos do Convênio PGE/OAB, no máximo legal previsto na tabela, liberando-se 70% (setenta por cento) em caso de recurso.

Condeno o réu, ainda, ao pagamento das custas, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, ressaltando-se, como já se decidiu: "Ainda que os apelantes estejam assistidos pela Defensoria Pública, impõe-se a condenação ao pagamento das custas processuais, devendo a alegada miserabilidade jurídica ser examinada pelo Juízo da Execução, a fim e se conceder ou não a isenção reclamada (...)" [STJ, REsp 1416725/MG, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 29.06.2015].

P.I.C.

Cubatão, 04 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA